

1501386-23.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... criminosa, efetivamente atuavam no tráfico de drogas.

MARCELO FRANCISCO comandava essa associação voltada ao tráfico, vendendo drogas em porções brutas para outros traficantes.

LUCIANA RAFAELA FABIO, companheira de MARCELO FRANCISCO, auxiliava nas vendas, entregas e armazenamento da droga.

HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES auxiliava nas vendas e entregas da droga.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501386-23.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501386-23.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2340462/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 21953312 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 103/21/567 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2340462 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANA RAFAELA FABIO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

LUCIANA RAFAELA FABIO, MARCELO FRANCISCO E HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia "em data, horário e local incertos, mas até o dia 14/12/2021, por volta das 13:00 horas, nesta cidade, os denunciados se associaram para o fim de praticarem crimes de tráfico ilícito de drogas. De maneira estável, passaram a adquirir drogas e revendê-las a pequenos traficantes e usuários

desta cidade. Para tanto, adquiriram aparelhos de telefonia celular e providenciaram a divisão de tarefas.

Durante os trabalhos de investigação, autorizada por decisão judicial, processo de número 1508606-89.2021.8.26.0071, que decretou a quebra do sigilo telefônico das citadas linhas, apurou-se que os usuários das linhas interceptadas, os denunciados por essa associação criminosa, efetivamente atuavam no tráfico de drogas.

MARCELO FRANCISCO comandava essa associação voltada ao tráfico, vendendo drogas em porções brutas para outros traficantes.

LUCIANA RAFAELA FABIO, companheira de MARCELO FRANCISCO, auxiliava nas vendas, entregas e armazenamento da droga.

HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES auxiliava nas vendas e entregas da droga.

A interceptação telefônica autorizada judicialmente através do processo 1508606-89.2021.8.26.0071, possibilitou deixar clara a relação entre LUCIANA RAFAELA FABIO, MARCELO FRANCISCO E HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES.

Durante o trabalho desenvolvido foi possível apurar o modo de agir desta organização criminosa e constatar que HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES havia pego maconha pertencente a MARCELO FRANCISCO, sem sua autorização e estava comercializando. Também foi apurado que esta droga estava no apartamento nº 12, do bloco 03, do condomínio 3 Américas, onde Policiais Civis foram atendidos por Grazielle Cristina Toniatto, que autorizou a entrada em seu apartamento, onde foi encontrado HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES na posse de 01 tablete de maconha pela metade embalado em plástico de cor verde.

Grazielle disse ser moradora do imóvel e que HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES era seu amigo e ele havia trazido a droga para seu apartamento sem seu consentimento. Ao ser cientificado da investigação e que já havia sido visto pegando drogas em um imóvel em estado de abandono na Rua Gonçalves Dias, nº10-19, HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES, após receber voz de prisão, admitiu informalmente que o local era a residência de uma outra investigada e neste imóvel ficava armazenada a droga do grupo.

Ao lado deste imóvel, em um terreno baldio, foram encontrados 06 tabletes de maconha em formato de tijolo, embalados em plástico verde, exatamente igual ao meio tablete encontrado na posse de HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES e que disse que MARCELO FRANCISCO lhe pertencia. Neste local também foi apreendida 01 balança de precisão"

Os acusados foram notificados às fls. 210, 212 e 214, e apresentaram resposta à acusação às fls. 221/226 e 230.

A denúncia foi recebida às fls. 270/271 e os réus foram citados às fls. 334, 336 e 338.

Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 452 e 483/484), as testemunhas de acusação e defesa foram inquiridas, oportunidade na qual foi homologada a desistência da testemunha Juliana Aparecida Tartarelli Batista, findando-se com o interrogatório dos réus MARCELO e LUCIANA.

Foi declarado a extinção da punibilidade em relação ao réu HENRIQUE PAULI DIAS GONCALVES, nos termos do art. 107, I do CP às fls. 495 em decorrência de sua morte.

Nos memoriais de fls. 506/530, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, que sejam

considerados os antecedentes criminais. Por fim, pugnou pela não aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Nos memoriais de fls. 536/608, a defesa dos réus MARCELO e LUCIANA requereu, preliminarmente, que seja reconhecida I. a violação de domicílio dos acusados e, consequentemente, o reconhecimento da ilegalidade do flagrante, bem como das demais provas decorrentes do ato. II. a nulidade das provas decorrentes da interceptação telefônica, e III. Reconhecimento da nulidade quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, pugnou pela absolvição dos réus com base no art. 386, incisos V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu que seja concedido aos réus o benefício de recolher em liberdade. Em relação a ré LUCIANA, a concessão da prisão domiciliar, bem como a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06, o cumprimento de pena aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito.

É o relatório.

D E C I D O.

Encerrada a instrução, o pedido condenatório comporta parcial procedência. O conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para alicerçar a condenação dos réus somente com relação ao delito de tráfico de drogas.

A preliminar de nulidade do processo por ilegalidade da prova colhida no interior da residência do réu e, consequentemente, de sua prisão, também não prospera. Isso porque o réu se fazia acompanhar dos policiais, que somente ingressaram no imóvel porque o réu estava com eles do lado de fora.

O crime de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" é permanente, e havia situação de flagrante delito a justificar o ingresso no domicílio.

Muito embora a Constituição Federal tenha estabelecido a inviolabilidade do domicílio (cf. artigo 5º, inciso XI), é preciso reconhecer que tal direito não é absoluto, sendo inaceitável que a prerrogativa constitucional seja agora usada para acobertar e incentivar práticas ilícitas.

Note-se que, com esse propósito, a própria Constituição Federal ressalvou os casos em que é possível quebrar a inviolabilidade da casa, mesmo sem a autorização do morador ou determinação judicial, sendo a ocorrência de flagrante delito uma dessas possibilidades, exatamente como na hipótese dos autos.

Portanto, não há falar-se em ilicitude da prova colhida, razão pela qual se impõe o reconhecimento de que não houve violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

As preliminares arguidas sobre a ilicitude da prova colhida por meio das interceptações telefônicas também não comportam acolhida.

Diferentemente do sustentado pela defesa, a Lei 9.296/96 não obriga a redução a termo de todo o conteúdo das conversas monitoradas, bastando a apresentação dos dados e a transcrição dos diálogos que interessam ao deslinde da controvérsia. Diálogos que não possuem qualquer relação com os fatos investigados devem ser excluídos, não apenas pela desnecessidade aos autos como também em respeito à intimidade dos investigados e interlocutores.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"É desnecessária a juntada do conteúdo integral das gravações das escutas

telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República)". (STF, HC 91.207, Rel. Min. Carmén Lúcia, j. 11.06.07).

Ademais, a Lei 9.296/96, em seu art. 6º, § 2º, determina que "cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas" e, em seu art. 9º, prevê que "a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada", donde se infere que a degravação deve ser apenas do conteúdo que interessa à investigação, e não de todo o conteúdo interceptado o que poderia ensejar uma indevida invasão à privacidade do investigado, violando direito constitucionalmente assegurado.

A nulidade poderia ser cogitada se trechos dos diálogos monitorados e transcritos tivessem sido editados fraudulentamente para induzir o julgamento em uma ou em outra direção. No entanto, não é o caso dos autos, pois as mídias com os diálogos captados poderiam ter sido solicitadas pelas partes para consulta, podendo, se assim quisessem, conferirem a autenticidade do conteúdo. Dessume-se, portanto, que inexistiu prejuízo às defesas.

Além disso, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto aos réus em decorrência da transcrição parcial dos diálogos interceptados realizada pelos policiais civis. Como é sabido, no âmbito do processo penal, a nulidade somente será declarada se evidenciado o prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESCABIMENTO. PENAL. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E JUDICIAIS. TESTEMUNHAS. BREVE CONSULTA A APONTAMENTOS. POSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO. SUFICIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TRANSCRIÇÃO POR PERITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 4. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a partir da interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, é desnecessária a degravação dos diálogos em sua integralidade. É suficiente que sejam degravados os trechos relevantes, desde que todo conteúdo seja disponibilizado às partes, como no caso concreto. Na espécie, não se demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto em razão da transcrição parcial dos diálogos interceptados e, conforme compreensão deste Colegiado, para se declarar a nulidade atinente à transcrição parcial das interceptações telefônicas, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, mormente quando se alcança a finalidade a que o ato se destina, consoante o disposto no art. 563, do Código de Processo Penal (REsp n. 1.381.695/RS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe26/08/2015). [...] 6. É desnecessário que a transcrição dos diálogos seja realizada por perito oficial, dada a falta de previsão legal" (STJ, HC 145.474, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6/04/2017).

Desse modo, a transcrição parcial dos diálogos realizada pelos policiais civis é válida.

No mais, no que concerne à alegação de nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, diferentemente do sustentado pela defesa, não se vislumbra ausência de fundamentação ou motivação nas decisões que autorizaram as

interceptações telefônicas. Isso porque foi especificada a impossibilidade de se colher a prova por outros meios, tendo a decisão proferida em 08 de outubro de 2021 nos autos nº 1508606-89.2021.8.26.0071 (consulta realizada pelo sistema eSaj) ressaltado que " presentes os requisitos legais, e, ainda, considerando não haver outro meio de obtenção da prova.". Ademais, a fundamentação das decisões valeu-se dos elementos veiculados pelo representante do Ministério Público e pela autoridade policial em seus pedidos que apontavam elementos indiciários suficientes à concessão da medida cautelar. O fato do nobre magistrado que concedeu as autorizações ter se valido da técnica da motivação per relationem, por si só, não implica em ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS" - ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - POSSIBILIDADE - PERÍODO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS EM CADA RENOVAÇÃO - PRECEDENTES - PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA - VIABILIDADE, DESDE QUE A INSTAURAÇÃO FORMAL DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO TENHA SIDO PRECEDIDA DE AVERIGUAÇÃO SUMÁRIA, "COM PRUDÊNCIA E DISCRICÃO" DESTINA A APURAR A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS DELATADOS E DA RESPECTIVA AUTORIA - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF, Segunda Turma, HC 121271 PE, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/05/2014).

Válida, portanto, as interceptações realizadas durante a investigação criminal. Afastadas as preliminares arguidas, adentra-se ao mérito.

A materialidade delitativa vem estampada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/03, boletim de ocorrência de fls. 12/15, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de constatação de fls. 21/25, laudo pericial de fls. 144/147, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria é, igualmente, inconteste.

O réu MARCELO, em sua autodefesa, narrou que na data dos fatos estava trabalhando em seu ferro velho quando os policiais chegaram e lhe deram voz de prisão. Não entendeu o motivo de estar sendo preso. Os policiais revistaram o local, mas não encontraram nada de ilícito. Posteriormente, revistaram também a sua residência e, inclusive, algemaram a sua sogra durante a abordagem. Informou que a equipe policial não tinham autorização para adentrarem em sua residência e nem no ferro velho. Nada de ilícito foi encontrado nos dois locais. No ferro velho, trabalha com a compra de metais, cobre, ferro e materiais recicláveis. Trabalha sozinho e não possui funcionários. Possuía apenas um carro junto de sua esposa, mas nunca teve um veículo estilo "kombi". Quando foi até a sua residência junto com os policiais, a sua esposa LUCIANA estava chegando no local e a prenderam também. Informou que o corréu HENRIQUE não estava presente durante as abordagens. Por fim, disse que não tem envolvimento com o tráfico de drogas.

A ré LUCIANA, em sua autodefesa, disse que trabalha com a venda de hortifrutis, frutas e comidas prontas. Na data dos fatos, saiu cedo para trabalhar e foi até a fazenda Santa Isabel para comprar lichias. Retornou à Bauru e saiu entregar algumas encomendas da referida fruta. Quando foi até a sua casa para almoçar, encontrou os policiais no local e eles lhe deram voz de prisão. Revistaram o seu carro, mas encontraram apenas a sua mercadoria de trabalho. Questionou o que estava acontecendo, mas ninguém lhe explicou a situação. Foi algemada e levada até a delegacia. Informou que possuiu o número (14) 988090137 durante um tempo, mas o perdeu em uma feira. Após alguns meses, começou a receber ligações informando tentativas de empréstimo de dinheiro em seu nome. Alguém estava usando os

documentos cadastrados no antigo celular perdido. Depois de um tempo, a sua operadora de celular "Oi" parou de existir em Bauru e, com isso, conseguiu fazer a portabilidade do número referido para outra operadora. Contudo, constantemente recebe ligações de pessoas chamadas "Aparecida", "Patrícia" e "Osvaldo" acerca de cobranças, mas não sabe quem são essas pessoas. Informou que possui 4 filhos, tendo eles 22, 15, 11 e 5 anos de idade. O seu filho Gabriel Henrique de 5 anos é portador de surdez e déficit de atenção na qual é total responsável por ele. Nunca teve envolvimento com tráfico de drogas e nunca consumiu drogas ou álcool pois não quer dar esse exemplo aos filhos. Em sua rotina, acorda cedo e vai para a roça fazer sua colheita, depois leva os filhos para a escola e abre a sua quitanda. Além disso, também cuida da casa e trabalha até tarde da noite visto que faz entrega para os clientes que trabalham o dia inteiro e não possuem tempo de ir até o local fazer a compra.

O policial civil WESLEY BELLONI VIEIRA narrou que receberam a informação de que os corréus MARCELO e HENRIQUE estariam comercializando grande quantidade de drogas. MARCELO seria o dono do ponto de vendas, bem como responsável pela venda no atacado para outros traficantes. Iniciaram os trabalhos de investigações e constataram que o acusado MARCELO possuía um ferro velho e HENRIQUE era seu funcionário. O local era constantemente frequentado por diversos traficantes conhecidos nos meios policiais. Com isso, solicitaram a quebra do sigilo telefônico e, através dos trabalhos de escuta, obtiveram certeza acerca das atividades ilícitas. Em uma das ocasiões, um funcionário do ferro velho liga para MARCELO informando-o que está com um possível comprador e pergunta o preço de meio saco de "estercó". MARCELO responde que consegue fazer por R\$ 1.400,00 reais. Na ocasião, conseguiram constatar que "estercó" era o termo usado para se referir a droga maconha. Identificaram um indivíduo de nome Leonardo que seria responsável pelo gerenciamento do ponto de drogas. Solicitaram a interceptação telefônica do celular de Leonardo e conseguiram captar diversas conversas de pessoas solicitando entorpecentes ou pedindo para que o suspeito fosse retirar o dinheiro das vendas. Em uma das ligações com o réu MARCELO, o acusado pede para Leonardo cinco "garrafinhas", se referendo a pinos de cocaína, e o suspeito respondia que levaria as que estava pronta para não correr perigo de "misturar" com as demais, ou seja, as que eram destinadas a venda. Constataram, também, que o armazenamento dos entorpecentes era feito por diversos indivíduos, sendo eles uma pessoa de vulgo "Burro", um indivíduo identificado como "Gui" e uma mulher de nome "Angélica". No decorrer da investigação, entenderam que o grupo citado acima parou de armazenar as drogas em determinado momento. Em algumas ligações, conseguiram interceptar conversas da ré LUCIANA questionando MARCELO sobre dinheiro e, em algumas delas, ela questionada se havia algo na casa de um indivíduo de vulgo "Gu" visto que ele havia brigado na rua e estava com medo de os policiais irem até a casa dele e encontrarem entorpecentes. Em outra ligação, LUCIANA questionada se tem algo na casa de um indivíduo identificado como "Gui" porque estava com medo de os policiais irem até o local também. Na data dos fatos, o réu MARCELO recebeu uma ligação de uma mulher desconhecida na qual ela o questiona acerca de "negócios de maconha" com o acusado HENRIQUE. De início, MARCELO fica com receio de falar algo e questiona o motivo da pergunta. A mulher responde que HENRIQUE a havia oferecido o entorpecente para a compra. Neste momento, MARCELO fala que a maconha vendida por HENRIQUE era sua e pergunta se o acusado está na casa dele. A mulher informa que o réu havia ido embora, mas que ligaria para MARCELO se soubesse de algo. Alguns minutos depois, a mulher retorna a ligar para MARCELO e informa que HENRIQUE está no apartamento de uma mulher chamada "Grá" e a maconha está armazenada no local. MARCELO, então, diz que conhece a mulher e informa o endereço do referido apartamento. Logo em seguida, interceptaram uma ligação de LUCIANA para uma mulher chamada Juliana, que era a atual responsável pelo armazenamento da droga, e questiona se HENRIQUE havia pegado algo com ela. Juliana responde que o réu havia pegado uma peça de maconha. Neste momento, a equipe se dirigiu até o apartamento de Graziela, que a franqueou a entrada dos policiais ao local, e encontraram HENRIQUE. O réu indicou o local em que estava armazenando o entorpecente e encontraram meio tijolo dentro da

geladeira. Questionaram o acusado acerca de uma casa na rua Gonçalves Dias. O local referido era apontado pelos militares como o principal ponto de armazenamento da droga. Em uma ocasião, o acusado HENRIQUE foi visto saindo daquele endereço com uma sacola na mão, passou pelo ferro velho e se dirigiu até a pizzaria de Leonardo. Acerca dessa atividade, foram feitos registros fotográficos do acusado no dia. Levaram o réu até o local indicado pelo próprio, que consistia em uma casa de aparência abandonada. No quintal do local, encontraram uma sacola contendo três tijolos de entorpecentes e uma balança de precisão. HENRIQUE assumiu a propriedade da droga. Dirigiram-se até o ferro velho e encontraram MARCELO no local. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, apenas a quantia de R\$ 2.000,00 reais em dinheiro. Em seguida, foram até a residência de MARCELO e encontraram LUCIANA no local. Deram voz de prisão aos três acusados e os levaram até a delegacia.

O policial civil RAPHAEL COSTA FERREIRA DOS SANTOS, relatou que receberam a informação de que os réus MARCELO e HENRIQUE estavam vendendo entorpecentes para traficantes de BAURU. Além disso, MARCELO possuía uma biqueira conhecida como "biqueira das águas da grama", sendo um dos pontos de drogas mais rentáveis de Bauru. Tomaram conhecimento de que MARCELO possuía um ferro velho na rua São Sebastião e que HENRIQUE era seu funcionário. Realizaram alguns trabalhos de campana e constataram que o local era frequentado por vários traficantes conhecidos. Assim, solicitaram a interceptação telefônica do celular dos acusados e conseguiram constatar a venda de entorpecentes para outros traficantes, além de que MARCELO era o proprietário da biqueira. Em uma das conversas interceptadas, um indivíduo liga para MARCELO e o questiona acerca do preço de um saco de "esterco", na qual responde que faria por R\$ 1.400,00 reais. Foi constatado que "esterco" era um termo para maconha. Em relação ao acusado HENRIQUE, verificou-se que as entregas eram feiras por ele e, por muitas vezes, com uma peruca que ficava no ferro velho. Também conseguiram fotografar o acusado em uma casa na rua Gonçalves Dias, na qual o réu saiu da referida residência, passou no ferro velho de MARCELO e foi até um estabelecimento comercial de um indivíduo chamado Leonardo e lhe entregou uma sacola. Na ocasião, constataram que o Leonardo era o responsável pelo abastecimento da biqueira. Ainda em relação a Leonardo, constataram através da quebra telemática imagens do indivíduo pesando drogas, conversas no WhatsApp na qual fazia menção a venda de 25 quilos de entorpecentes, além de uma imagem na qual era possível visualizar a mistura de cocaína para colocar nos pinos eppendorffs. Em relação a ré LUCIANA, ela era responsável pela guarda do dinheiro advindo das drogas. Durante diálogos interceptados, LUCIANA fala para MARCELO sobre uma pessoa que queria armazenar os entorpecentes e questiona quantos pedaços de "bolo" o réu queria que fosse armazenado. Na data da prisão dos réus, o réu MARCELO recebeu uma ligação de uma mulher chamada ANA, na qual ela pergunta se ele teria alguma coisa com HENRIQUE relacionado a maconha. MARCELO fica receoso, mas conta que a maconha que HENRIQUE comercializava era sua. Em seguida, Ana fala que HENRIQUE estava na casa de uma pessoa chamada "Grá" e MARCELO fala o endereço da referida residência. A equipe policial se dirigiu até o local indicado e localizaram HENRIQUE e a testemunha Graziela. Na geladeira do apartamento, localizaram maconha. HENRIQUE acabou confessando que a residência na rua Gonçalves Dias se tratava de um local para armazenamento de entorpecentes. Dirigiram-se até o local e encontraram alguns tablets de maconha no terreno ao lado da residência indicada. Por fim, esclareceu que os termos usados pelos réus durante a investigação para se referirem as drogas são termos comumente usados na traficância e, aliado a toda a investigação, não tem dúvidas sobre a referencia a entorpecentes.

O policial civil LEONARDO ALMAS DE ABREU informou que auxiliou na interceptação telefônica do celular de Leonardo. O suspeito era apontado como o gerente de MARCELO e responsável, junto de sua amazia, de acertar todo o trajeto da droga até as biqueiras, bem como recolher o dinheiro e entregar a MARCELO. Durante os trabalhos, houve diversos momentos em que Beatriz, amazia de Leonardo, está ao telefone tentando resolver problemas da biqueira durante a ausência do companheiro. Em outros momentos, era Leonardo no telefone e questionava acerca do progresso da

droga e se o produto estava pronto para a venda.

No que concerne ao depoimento dos policiais, nenhum fato concreto foi atribuído às testemunhas para desmerecer a qualidade da prova. Há que ser prestigiado, portanto, os depoimentos dos policiais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Depoimento de policiais - Validade - Declarações harmônicas e corroboradas com os demais elementos probatórios - Credibilidade - Recursos do réu parcialmente provido e do Ministério Público provido" (São Miguel Arcanjo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relator Sebastião Flávio da Silva Filho - 25/08/2009 - Voto nº: 1166).

A testemunha BRUNA JACOBS RIBEIRO GAGLIARDI informou que faz parte do escritório de inteligência da DETE e apenas presta apoio para as equipes e realiza as pesquisas que os delegados e investigadores solicitam. Acerca da investigação, informou que não fez parte dos trabalhos.

A testemunha CLAUDIA REGINA CAETANO informou que conhece a ré LUCIANA e que a mesma é uma pessoa trabalhadora. Possui filhos e cuida de todos eles. Na data dos fatos, foi até a casa da ré para irem juntas em uma fazenda comprar lichia. As duas foram na companhia de seus filhos. Chegaram no local e colheram a fruta. Retornaram para a cidade e foi junto de LUCIANA deixar as crianças na casa da ré. Posteriormente, foram até o ferro velho para pesar as frutas, uma vez que a balança da quitanda era apenas até 5kgs. Saíram fazer as entregas da fruta e quando retornaram para almoçar, encontraram os policiais na casa da acusada. Os policiais vieram ao encontro das duas e perguntaram quem era a LUCIANA. Informou que os policiais pegaram o seu documento e pediram para LUCIANA entrar em um carro e, logo em seguida, a levaram para algum lugar. Disse que ajuda a ré em dias alternados na quitanda. Conhece o acusado MARCELO de vista apenas. Por fim, disse que não sabe informar se LUCIANA trabalhava no ferro velho.

A testemunha CAROLINE CRISTINA MACOLONGO DOS SANTOS informou que conhece LUCIANA e que a acusada é uma pessoa trabalhadora. A ré é dona de uma quitanda e é cliente do estabelecimento. Sabe que a acusada possui filhos pequenos e grandes.

A testemunha ANA LAURA DA SILVA informou que conheceu o réu MARCELO há cerca de 1 ano atrás através de LUCIANA. Levava as suas reciclagens no ferro velho do acusado e compra legumes e frutas da quitanda da ré. Conhece LUCIANA há cerca de 5 anos e a mesma é uma pessoa trabalhadora e guerreira. O acusado Marcelo é uma pessoa boa e estava sempre sozinho no ferro velho.

A testemunha GRAZIELE CRISTINA TONIATTO relatou que era amiga do acusado HENRIQUE há cerca de 8 anos. Os dois se conheceram através de uma pessoa em comum e possuíam uma grande amizade. No dia da prisão do acusado, informou que ele estava em sua residência visto que estava morando temporariamente no local. Havia saído cedo pela manhã para ir até a casa de sua filha lavar roupas. Quando estava retornando para a sua residência, encontrou com HENRIQUE no caminho e foram juntos até o imóvel. Chegando no local, foi pendurar as roupas no varal. Cerca de cinco minutos depois, escutou um barulho forte e os policiais adentraram em sua residência. Informou que os policiais não pediram autorização para adentrar no local, apenas arrombaram a porta e apontaram a arma para a sua cabeça. Um dos policiais a pegou pelos braços e



gritou para ela contar onde estavam as drogas. Ficou muito nervosa e chegou a urinar nas calças. Disse que não sabia que havia drogas em sua casa. Apesar de o réu HENRIQUE estar residindo no local, não tinha conhecimento de pessoas com quem ele se relacionada. É usuária de crack e não passava muito tempo dentro de casa, geralmente saía e ficava na rua por cerca de 3 dias. Não encontrava frequentemente o acusado em casa. Após a abordagem, os militares se dirigiram até outra residência em outro bairro e ficou o tempo todo dentro do carro enquanto os policiais realizavam a abordagem. Posteriormente, foi encaminhada a delegacia de polícia junto de HENRIQUE.

A tese de autodefesa dos réus está em dissonância com a instrução probatória e suas negativas destoam do conjunto probatório.

Apesar da negativa da ré LUCIANA, foi comprovado através dos diálogos extraídos dos trabalhos de interceptação telefônica que a acusada tinha ciência do comércio de entorpecentes e atuava junto do marido, o réu MARCELO. Inclusive, em uma conversa registrada no dia 26/10/2021, hora inicial às 12h15min, LUCIANA cobra um funcionário que não apareceu para trabalhar. O referido indivíduo não identificado liga informando que há uma pessoa querendo comprar entorpecentes e a acusada o questiona do motivo de não ter ido trabalhar.

Com relação ao acusado MARCELO, ficou claro durante as investigações policiais que o réu era o dono do ponto de drogas. Durante os trabalhos de escuta policial, foi possível identificar diversos diálogos envolvendo a venda dos entorpecentes. Ressalta-se que na data da prisão dos réus, MARCELO utiliza expressamente o termo maconha e se demonstra irritado por HENRIQUE ter supostamente roubado a sua mercadoria e estar vendendo a terceiros.

No mais, o laudo pericial da droga, o auto de exibição e apreensão, aliados aos depoimentos contundentes e uníssomos dos policiais civis que participaram da abordagem dos réus forma um conjunto probatório coeso que não cede às alegações, desacompanhadas de provas do réu.

Contrariamente ao alegado pela defesa, as circunstâncias da apreensão denotam que a droga apreendida seria distribuída a terceiros, diante da quantidade das drogas (4.380 gramas de maconha em 07 porções) a forma de embalagem, aliada à forma como estavam acondicionadas. Os policiais civis afirmaram que receberam a informação de que MARCELO e HENRIQUE estavam traficando grande quantidade de entorpecentes para outros traficantes de BAURU, e ainda que MARCELO era dono de uma das biqueiras mais rentáveis da cidade. No dia da prisão dos acusados, uma mulher de nome Ana liga para MARCELO perguntando se ele havia um comércio de maconha junto de HENRIQUE. MARCELO fica receoso e a questiona do motivo. Ana responde que HENRIQUE o havia oferecido maconha para compra. MARCELO então responde que a droga comercializada por HENRIQUE era sua e a questiona se sabe da localização de HENRIQUE. Ana diz que ele está na casa de uma pessoa chamada "Grá". MARCELO responde que conhece a pessoa mencionada e indica o endereço dela. Neste momento, a equipe policial se dirigiu até o local indicado e realizaram a abordagem. No local, os policiais foram atendidos por Grazielle Cristina Toniatto, dona do apartamento, e localizaram o acusado HENRIQUE na posse de 01 tablete de maconha pela metade embalado em plástico de cor verde. O acusado, ao ser cientificado da investigação e que já havia sido visto pegando drogas em um imóvel em estado de abandono na Rua Gonçalves Dias, nº10-19, HENRIQUE admitiu que o local servia para a armazenagem da droga. A equipe se dirigiu ao local e, ao lado deste imóvel, em um terreno baldio, foram encontrados 06 tabletes de maconha em formato de tijolo, embalados em plástico verde, exatamente igual ao meio tablete encontrado na posse de HENRIQUE. Diante dos fatos, os policiais se dirigiram até o ferro velho de propriedade de MARCELO e realizaram a prisão do acusado, juntamente de sua esposa LUCIANA. Com MARCELO foram apreendidos R\$ 1.944,00 reais e um aparelho celular.

Portanto, as circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" e "ter em depósito" verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticados pelos réus.

A legislação antidrogas estabelece que para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. O contexto, a quantidade do produto (4.380 gramas de maconha em 07 porções), a forma de embalagem, e o local em que estava encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Ademais, insta salientar que não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente dos acusados, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, "guardar" e "ter em depósito", o que no caso dos autos não se discute. Destarte, a responsabilidade dos réus restou demasiadamente evidenciada.

Desta forma, não bastasse a prova oral produzida, já suficiente à condenação, a quantidade do produto, a forma em que foi encontrada, e o contexto em que aconteceu a apreensão do entorpecente, extirpam qualquer dúvida acerca da destinação comercial da substância entorpecente encontrada em poder dos réus.

De outro lado, assiste razão a defesa dos réus quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. Isso porque não há prova segura e suficiente acerca da associação dos réus para a prática do tráfico.

As provas colhidas são insuficientes para comprovar associação estável. Tem-se afirmado que "não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável" (MARCÃO, Renato, in Tóxicos, 4ª ed., p. 281).

A simples convergência ocasional de vontades para a prática do tráfico não configura o delito de associação. A configuração do delito exige prova do ajuste prévio para a formação de um vínculo associativo de fato, com certa estabilidade, ainda que para a prática do tráfico de forma "reiterada ou não", ônus do qual não se desincumbiu a acusação.

Sobre o tema, colaciona-se a doutrina de Vicente Greco Filho:

"O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação" (in "Lei de Drogas Anotada - Lei 11.343/06, 1º ed.; ed. Saraiva, p.120).

Esse é posicionamento do STJ:

"O tipo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo" (REsp 1113728-SC, 5ª T., rel. FELIX FISCHER, j. 29.09.2009, v.u.). "

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria do crime, bem como que agiram os réus com consciência e vontade de praticar o delito de tráfico de entorpecentes, procede em parte o pedido condenatório.

Passa-se à dosimetria.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/06) com relação à acusada LUCIANA.

Em relação ao réu MARCELO, verifica-se que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 93/94 – Processo de Execução 7000839-97.2007.8.26.0344 – com pena por cumprir; fls. 93 – Processo de Execução 7000588-57.2007.8.26.0071 – com pena cumprida e data fim da execução prevista para 10/09/2018; e fls. 94/95 – Processo de Execução 7001081-26.2012.8.26.0071 – com pena por cumprir). Observa-se que sua conduta social não lhe favorece, tendo, ainda, personalidade voltada ao crime, haja vista que praticou outros delitos. Afora isso, o réu tinha grande quantidade de entorpecentes em sua posse, razão pela qual sua culpabilidade não ficou restrita à prática do delito, gerando um círculo vicioso para alimentar a venda de drogas na sociedade. Portanto, exaspera-se a pena base em 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes com relação à LUCIANA.

Contudo, presente a agravante da reincidência específica em relação à MARCELO (fls. 94 – Processo de Execução 7001526-78.2011.8.26.0071 – com pena cumprida e data fim da execução prevista para 16/12/2017), razão pela qual majora-se a pena de 1/6, vindo a totalizar a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Deixa-se de reconhecer a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque embora a ré seja primária e não ostente maus antecedentes, está comprovado que se dedicavam à atividade criminosa.

A expressiva quantidade e o seu acondicionamento (4.380 gramas de maconha em 07 porções) não deixam dúvidas de que os réus não podem ser considerados traficantes esporádicos, mas sim demonstra que estão enveredados no mundo do crime. A partir desse contexto, mais não é preciso dizer para provar, concretamente, que os réus se dedicavam à atividade criminosa, não fazendo jus ao benefício de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme leciona Renato Marcão, a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa. A grande quantidade da droga, a propósito, atenta com maior intensidade contra o bem jurídico tutelado, porquanto inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo, e faz desaconselhar o reconhecimento do “tráfico privilegiado”. (Tóxicos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 138).

Além disso, anote-se que a agravante da reincidência do réu MARCELO impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – vol.1 –Ed. Forense – 8ª ed. – 2014 –

pagina 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso.

Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.". Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Desta forma, sendo o réu reincidente, impossível à concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela. Frise-se, por fim, que o réu ainda possuía grande quantidade de entorpecentes (4.380 gramas de maconha em 07 porções) de modo a demonstrar que se dedicava à atividade criminosa.

Para ambos dos réus, o regime de cumprimento será inicialmente o fechado porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto. Desse modo, no caso em apreço, as circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores subsidiados pelo artigo 59 do Código Penal, desaconselham a imposição de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos acima, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Com efeito, se as penas alternativas estão vedadas, com muito mais razão a suspensão condicional da pena, já que o espírito da lei foi trazer um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico de drogas, em consonância com a vontade do Poder Constituinte.

O tempo de prisão, para efeitos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não determina antecipação de regime prisional menos gravoso.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR LUCIANA RAFAELA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e MARCELO FRANCISCO à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; bem como para ABSOLVÊ-LOS da infração descrita no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Verifica-se que o acusado MARCELO foi preso em flagrante e, assim, respondeu ao processo. Desse modo, não se justifica seja colocado em liberdade após a formação da culpa por delito de inequívoca gravidade, ainda mais, considerando a permanência dos requisitos necessários à segregação cautelar, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, revelando-se inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em face de MARCELO.

Defiro a defiro à ré LUCIANA o recurso em liberdade, situação em que se encontra em relação a este processo.

CONDENO, ainda, os réus, ao pagamento das custas finais, fixadas em 100 UFESPs, caso não sejam beneficiários da gratuidade prevista no artigo 12 da Lei 1060/50.

Com o trânsito em julgado, proceda ao cálculo da multa e, em caso dos réus de não serem beneficiários da Justiça Gratuita, da taxa judiciária, dando-se vista às

partes para manifestação.

Por fim, não comprovada a origem lícita do valor apreendido (fls. 18/19), com o trânsito em julgado, decreto a perda em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, bem como determino a inutilização dos objetos apreendidos, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ para fins de estatística.

P.R.I.C.

Bauru, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA